

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.



گنه: ۱۸

نېټه: ۱۳۴۷/۸/۴ هـ ق

د زوجينو د تفريق اصولنامې د انفاذ په هکله د عاليقدر اميرالمؤمنين حفظه الله تعالى

فرمان

لومړۍ ماده:

د زوجينو د تفريق اصولنامه په (۱) مقدمه، (۲) بابونو، (۱۲) فصلونو او (۳۱) مادو کې توشېح کوم.

دوهمه ماده:

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ او د يادې اصولنامې له متن سره يو ځای دي په رسمي جريده کې خپور شي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

اميرالمؤمنين شيخ القرآن والحديث

مولوي هبة الله اخندزاده

- شعبان المعظم ۱۴۴۷ هـ ق -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^(١)

الحمد لله رب العلمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.^(٢)

د زوجينو د تفريق د اصولنامې

کتاب

د زوجينو د تفريق اصولنامه پر يوه مقدمه، دوو بابونو، دوولسو فصلونو او يو دېرش مادو مشتمله ده.

مقدمه

مقدمه له اصولو او قوانينو څخه مراد او اصطلاحگانې پر مادو مشتمله ده.

له اصولو او قوانينو څخه مراد

لومړۍ ماده:

په دې اصولنامه کې له اصولو او قوانينو څخه مراد، هغه اصول او قوانين دي چې د عاليقدر اميرالمؤمنين شيخ القرآن والحديث مولو هبة الله اخندزاده حفظه الله تعالى له خوا تاييد يا توشيح شوي وي.^(٣)

اصطلاحگانې

دوهمه ماده:

په دې اصولنامه کې راتلونکې اصطلاحگانې، لاندې معناگانې افاده کوي:

١- فرقت: د مېړه او مېرمنې ترمنځ د زوجيت د علاقې ختمېدو ته ويل کېږي.^(٤)

٢- تفريق: د مېړه او مېرمنې ترمنځ د زوجيت د علاقې ختمولو ته وايي.^(٥)



(١) (ابتداء الكتاب بالبسملة أولاً... اقتداء بالكتاب العزيز المستفتح هكذا، وعملًا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله وبسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع». رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في «أربعينه». وفي رواية «أبي داود» و«النسائي»: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» وفي رواية «ابن ماجه»: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» ورواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحهما). [البنية شرح الهداية، ج ١، ص ١٠٥، ط: دار الكتب العلمية، بيروت]. (٢) المرجع السابق.

(٣) وكذلك إن أمرهم بشيء لا يدرون أينفعون به أم لا، فعلمهم أن يطيعوه، لأن فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به وما تردد لهم من الرأي في أن ما أمر به منتفع أو غير منتفع به لا يصلح معارضا للنص المقطوع [شرح السير الكبير ج ١ ص: ١٦٥ الناشر: الشركة الشرقية للإعلانات].

- مطلب طاعة الإمام واجبة قوله (أمر السلطان إنما ينفذ) أي يتبع ولا تجوز مخالفته. [رد المحتار على الدر المختار ج ٥ ص ٤٢٢، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر].

- قال في المعراج لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة اه [حاشية رد المحتار على الدر المختار ج ٢ ص ١٧٢. دار الفكر للطباعة والنشر. بيروت].

- أنهم صرحوا أن المباح في نفسه قد يصير حراماً من حكم الأمير من جهة أن الله أمر بطاعتهم، فقال: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} فحينئذٍ لورأى الأمير أن يمنع الناس عن أكل شيء لمصلحة بدت له، يجب عليهم أن لا يأكلوه، ويحرم عليهم. [فيض الباري على صحيح البخاري ج ٢ ص ٤٠٨ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان].

- وظاهر كلامهم هاهنا أن السياسة هي فعل شيء من الحكيم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي. [البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ج ٥ ص ١١].

(٤) الفرقة: بضم فسكون الافتراق: الفصل بين الزوجين، وقد تكون هذه الفرقة طلاقاً وقد لا تكون طلاقاً. [معجم لغة الفقهاء، ص ١٣٩، ٣٤٤، ط: إدارة القرآن، كراتشي]. [كذا في المتنوفي القواعد الفقهية، ج ٣، ص ٢٤، ٢٥].

(٥) (التفريق من فرق: الفصل. التفريق بين الزوجين: منع الرجل من جماع زوجته بايقاع القاضي الطلاق عليه، كتفريق بينهما للعنة، أو بغير طلاق، كالتفريق بينهما للردة... [معجم لغة الفقهاء، ص ١٣٩، ٣٤٤، ط: إدارة القرآن، كراتشي]. [كذا في المتنوفي القواعد الفقهية، ج ٣، ص ٢٤، ٢٥].

۳- خيار بلوغ: د صغير يا صغيرې (باکړې او يا ټيږې) لپاره بعد البلوغ د نکاح د عقد د فسخي اختيار دی چې د هغوی نکاح، له پلار او نيکه پرته د نورو خپلوانو له خوا د يوه په واسطه د صغارت په وخت کې صورت موندلې وي.^(۱)

۴- مفقود: هغه غائب شخص دی چې د هغه ځای، ژوند او مړينه معلومه نه وي او کورنۍ يې د هغه په لټه کې وي، خو د هغه متعلق هېڅ خبر يا نښې ترلاسه نه کړای شي.^(۲)

۵- غيرمفقود غائب: هغه شخص دی چې له خپل کور او کلي څخه لرې په سفر تللی او ځای يې معلوم وي، خو ډېر وخت تېر کړي او خپله مېرمن يې په کور کې پرېښې وي، نه خپله راځي، نه خپله مېرمن له ځان سره بيايي، نه يې خرچ او نه نورې اړتياوې ورپورته کوي، نه طلاق ورکوي چې دغه وضعیت د مېرمنې لپاره ستونزمن وي.^(۳)

۶- خلغ: په لفظ د خلعي سره د ملک نکاح د ختمولو په بدل کې پيسې اخيستل دي.^(۴)

۷- متعنت: هغه شخص دی چې د خپلې مېرمنې نفقه او د زوجيت حقوق د توان په لرلو سره نه اداء کوي.^(۵)

۸- لعان: له لعن او غضب سره په قسمونو مؤکد کړی شوي شهادتونه دي، چې د مېرمن په حق کې قايم مقام د ځان قذف او د مېرمنې په حق کې قايم مقام د حد زنا دي.^(۶)

۹- ظهار: د مسلمان، عاقل او بالغ مېرمن د خپلې منکوحې د ټول بدن او يا د ځينې اعضاوو چې له هغو څخه تعبير په ټول بدن کې شای شي يا په جزء شایع سره د اتفاقي محرمات علی التأيید له هغه عضوي سره تشبيه ورکول دي چې د ده کتل ورته حرام وي.^(۷)



(۶) - (وإن كان المزوّج غيرهما) أي: غير الأب وأبيه ولو الأم أو القاضي أو وكيل الأب، لكن في «التهر» بعثاً لوعين لوكيله القدر صبح. (لا يصح) النكاح (من غير كفاء أو يغبين فاحشي أصلاً) وما في صدر الشريعة: صبح ولهما فسخه وهم (وإن كان من كفاء وبمهر المثل صبح) لكن (لهما) أي: لصغير وصغيرة وملحق بهما (خيار الفسخ) ولو بعد النحول (بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده) لقصور الشفقة. [التنوير والدرع على هامش رد المحتار، ج ۳، ص ۶۷، ط: إيج ايم سعيد، كراتشي].

- (ومنها اختيار الصغير أو الصغيرة بعد البلوغ في خيار البلوغ، وهذه الفرقة لا تقع إلا بتفريق القاضي). [بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۳۳۶، ط: دار الكتب العلمية، بيروت].

- (وخيار الصغير والنيب إذا بلغا لا يبطل) بالسكوت (بلا صريح) رضا (أو دلالة) عليه (كقبلة ولمس) ودفع مهر (لا) يبطل (بقيامهما عن المجلس): لأن وقته العمر، فيبقى حتى يوجد الرضا ولو ادعت التمكين كرهما صدقت. [التنوير والدرع على هامش رد المحتار، ج ۳، ص ۷۵، باب الولي، ط: إيج ايم سعيد، كراتشي]. [كذا في الخانية على هامش الهندية ج ۱ ص ۳۵۷، ط: مكتبة حبيبيه، كويت].

(۷) المفقود: وفي اصطلاح الفقهاء: غائب لم يدر موضعه وحياته وموته، وأهله في طلبه يجدون وقد انقطع عنهم خبره وخفي عليهم أثره. تبين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلي (ج ۳ ص ۳۱۰) المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

(۸) [الحيلة الناجزة، ص ۱۳۲، ۱۳۳، ط: كراتشي].

(۹) الخلغ: وفي الشرح: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلغ وشرطه: شرط الطلاق وحكمه: وقوع الطلاق البائن وصفته: يمين من جهته معاوضة من جهتها. تبين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلي (۲/ ۲۶۷) المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة.

الخلغ: إزالة ملك النكاح بأخذ المال. التعريفات (ص: ۱۰۱) الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان

(۱۰) (التعنت: مصدر تعنت الشيء: أدخل عليه المشقة. التمسك بالرأي بغير وجه حق). [معجم لغة الفقهاء، ص ۱۳۷، ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي].

- (قال ابن الأثيري: أصل التّعنت التّشديد، فإذا قالت العرب: فلان يتعنّت فلاناً ويعنته، فمراهم يشدّد عليه، ويلزمه بما يصعب عليه أدائه). [لسان العرب، ج ۲، ص ۶۱، ط: دار صادر، بيروت].

- (وأما المتعنت في اللغة فهو من يطلب العنت، وهو الوقوع فيما لا يستطيع الإنسان الخروج عنه، كذا في «البنية»).

[البحر الرائق، ج ۶، ص ۲۸۱، ط: دار الكتب الشرعية والأدبية، كويت].

(۱۱) اللعان: هي شهادات مؤكّدة بالأيمان مقرونة باللّعن قائمة مقام حد القذف في حقّه، ومقام حد الزّنا في حقّها. كتر الدقائق (ص: ۳۰۱) الناشر: دار البشائر الإسلامية، دار السراج.

(۱۲) قال - رحمه الله - (هو تشبيه المنكوحه بمحرمة عليه على التأييد) وزاد في النهاية لفظة اتفاقاً ليخرج أم المزمي بها وبنتها لأثمة لو شهبها بما لا يكون مظاهراً ... وأهله من كان أهلاً لسان التصرفات وهو العاقل البالغ. (تبين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلي (ج ۳ ص ۲)

- (هو تشبيه المنكوحه بمحرمة عليه على التأييد) أراد بالمنكوحه ما يصح إضافة الطلاق إليه من الزوجة وهو أن يشهبها أو عضواً منها يعبر به عنها أو جزءاً شائعاً منها لما سيأتي وأراد بالمشبه به عضواً يحرم إليه النظر من عضو محرمة عليه على التأييد لما سنذكره أيضاً، وأراد بالزوج المسلم: لأنه لا ظهار للذمي عندنا. (البحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (ج ۴ ص ۱۰۲)

۱۰- کفانت : د مېره برابر والی د مېرمنې سره په حسب ، نسب ، دین ، عمر او داسې نورو اوصافو کې دی. (۱۳)

لومړی باب د تفریق اسباب



دغه باب پر دوولسو فصلونو مشتمل دی:

لومړی فصل: د نه کفانت په سبب تفریق؛

دوهم فصل: د خیار بلوغ په سبب تفریق؛

درېم فصل: د رضاعت په سبب تفریق؛

څلورم فصل: د حرمت مصاهره په سبب تفریق؛

پنځم فصل: د مفقودوالي په سبب تفریق؛

شپږم فصل: د خلع او غیابت په سبب تفریق؛

اووم فصل: د متعنتوالي په سبب تفریق؛

اتم فصل: په مېره کې د عیب د شتون په سبب تفریق؛

نهم فصل: د ردت په سبب تفریق؛

لسم فصل: له اسلام څخه د اعراض په سبب تفریق؛

یوولسم فصل: د دارینو د اختلاف په سبب تفریق؛

دوولسم فصل: د لعان او ظهار په سبب تفریق؛

لومړی فصل د نه کفانت په سبب تفریق

نه کفانت

دریمه ماده:

هغه ښځه چې د ولي د شتون په صورت کې، د ولي له اجازې پرته له غیر کفو سره نکاح وکړي، نکاح یې صحت نه لري. (۱۴)

د کفانت په نه شتون کې د نکاح د فسخه کولو واک

څلورمه ماده:

که د ښځې ولي، د ښځې په اجازه، هغه یو داسې شخص ته په نکاح کړي چې د هغه کفانت معلوم نه وي او ښځې یا ولي د نکاح په وخت کې کفانت شرط گرځولی وي، وروسته معلومه شي چې هغه شخص کفو نه دی، نو په دې صورت کې ولي او ښځه د نکاح د فسخه کولو اختیار لري، البته دغه تفریق د محکمې په حکم سره صورت مومي. (۱۵)

(۱۳) وهوان يكون الزوج مساويا للمرأة في حسنها ونسبها، ودينها، وسنها وغير ذلك. [البنایة شرح الهدایة (ج ۵ ص ۱۰۷) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان].

(۱۴) (فنقد نکاح حرّة مكفّاة بلا رضا (ولي) ... (وله) ... (إذا كان عصبة) ... (الاعتراض في غير الكفاءة) ... (ما لم) ... (تلد منه) ... (وفيق) في غير الكفاءة (بعدم جوازه أصلاً) وهو المختار للفتوى: (فساد الزمان). [التنوير والدرع على هامش رد المحتار، ج ۳، ص ۵۶، ط: ایچ ایم سعید، کراتشي].

- (قوله: وتفریق بعدم كفاءة) ومثله عدم مهر المثل. ولا يخفى أن هذا في البالغة التي زوجت نفسها بلاولي، فإن العقد يصح في ظاهر الزوايه، وللولي حق الفسخ، لكن المفتي به الآن بطلانته. [رد المحتار، ج ۳، ص ۶۰۹، ط: ایچ ایم سعید، کراتشي].

(۱۵) - (ولو زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة، ثم علموا لا خيار لهن، إلا إذا شرطوا الكفاءة أو أخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك، ثم ظهر أنه غير كفء، كان لهن الخيار «ولو الجبة» فليحفظ. [الدرع على هامش رد المحتار، ج ۳، ص ۸۵-۸۶، باب الكفاءة، ط: ایچ ایم سعید، کراتشي].

دوهم فصل د خيار بلوغ په سبب تفريق

خيار بلوغ

پنځمه ماده:

که له پلار او نيکه پرته له خپلوانو څخه يو، د صغير يا صغيرې (باکره وي او که ټيټه) د نکاح عقد، له کفو سره په مهر مثل باندې وکړي، عقد صحيح دی، خو د بلوغ په وخت کې د نکاح د عقد د فسخې خيار د ياد شوي صغير يا صغيرې لپاره دی، البته دغه فسخ به د محکمې په حکم سره صورت مومي. (۱۶)

له غيرکفو سره د صغير يا صغيرې نکاح او يا په مهر کې فاحش غبن

شپږمه ماده:

که له پلار يا نيکه پرته له خپلوانو څخه يو، صغير يا صغيره له غيرکفو يا د فاحش غبن په مهر سره په نکاح کې وکړي، نکاح يې صحيح نه لري. (۱۷)

د خيار بلوغ باطلېدل او نه باطلېدل

اوومه ماده:

د باکرې خيار بلوغ، په سکوت سره باطلېږي او د هلک او ټيټې خيار بلوغ په سکوت سره نه باطلېږي، خو د رضا په ښکاره کولو سره صراحتاً وي که دلالتاً، باطلېږي. (۱۸)

د پلار او نيکه سوء اختيار

اتمه ماده:

(۱) که پلار يا نيکه، کوچنی لور يا لمسی په نکاح ورکړي وي او د شفقت معامله يې ورسره نه وي کړي او ياد پلار يا نيکه په سوء اختيار معروف نه وي نو په دې صورت کې لور يا لمسی د بلوغ په وخت کې اختيار لري چې محکمې ته د نکاح د عقد د فسخې لپاره مراجعه وکړي. (۱۹)

- (ومنها التفريق لعدم الكفاءة أو لنقصان المهر، والفرقة به فرقة بغير طلاق؛ لأنها فرقة حصلت لا من جهة الزوج، فلا يمكن أن يجعل ذلك طلاقاً؛ لأنه ليس لغیر الزوج ولاية الطلاق، فيجعل فسخاً، ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي، لما ذكرنا في الفرقة بخيار البلوغ).

[بدائع الصنائع، ج ۶، ص ۱۸۳، ط: دار الكتب العلمية، بيروت].

- (وإن كان المزوج غيرهما) أي: غير الأب وأبيه ولوالأم أو القاضي أو وكيل الأب، لكن في «التهر» بحثاً لوعين لوكيله القدر صخ. (لا يصح) النكاح (من غير كفو أو يغبني فاحش أصلاً) وما في صدر الشريعة: صح ولهما فسخه وهم (وإن كان من كفو وبمهر المثل صح) و لكن (لهما) أي: لصغير وصغيرة وملحق بهما (خيار الفسخ) ولو بعد الدخول (بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده) [لقصور الشفقة]. [التنوير والدر على هامش رد المحتار، ج ۳، ص ۶۷، ط: ايج ايم سعيد، كراتشي].

(۱۶) (وإن كان المزوج غيرهما) أي: غير الأب وأبيه ولوالأم أو القاضي أو وكيل الأب، لكن في «التهر» بحثاً لوعين لوكيله القدر صخ. (لا يصح) النكاح (من غير كفو أو يغبني فاحش أصلاً) وما في صدر الشريعة: صح ولهما فسخه وهم (وإن كان من كفو وبمهر المثل صح) و لكن (لهما) أي: لصغير وصغيرة وملحق بهما (خيار الفسخ) ولو بعد الدخول (بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده) [لقصور الشفقة]. [التنوير والدر على هامش رد المحتار، ج ۳، ص ۶۷، ط: ايج ايم سعيد، كراتشي].

(۱۷) المراجع السابقة.

(۱۸) - (ومنها اختيار الصغير أو الصغيرة بعد البلوغ في خيار البلوغ، وهذه الفرقة لا تقع إلا بتفريق القاضي). [بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۳۳۶، ط: دار الكتب العلمية، بيروت].
- (وخيار الصغير واليتيم إذا بلغا لا يبطل) بالسكوت (بلا صريح) رضا (أو دلالة) عليه (كقبلة ولمس) ودفع مهر (لا) يبطل (بقيامهما عن المجلس): لأن وقته العمر، فيبقى حتى يوجد الرضا ولو ادعت التمكين كرها صدقت. [التنوير والدر على هامش رد المحتار، ج ۳، ص ۷۵، باب الولي، ط: ايج ايم سعيد، كراتشي]. [كذا في الخانية على هامش الهندية ۱/ ۳۵۷، ط: مكتبة حبيب، كويت].

(۱۹) - (سئل) في الأب إذا علم منه سوء الاختيار وعدم النظر في العواقب إذا زوج ابنته القابلة للتخلق بالخير والشر بغير كفو هل يصح أم لا؟ (أجاب) قال ابن فرشته في شرح المجمع لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لايجوز العقد اتفاقاً ومثله في الدرر والغرور وقال في البحر في شرح قول الكتولو زوج طفله غير كفو أو يغبني فاحش صح ولم يجز ذلك لغیر الأب والجدة أطلق في الأب والجدة وقيد الشارحون وغيرهم بأن لا يكون الأب معروفاً بسوء الاختيار حتى لو كان معروفاً بذلك مجاناً وفسقاً فالعقد باطل على الصحيح قال في فتح القدير ومن زوج ابنته الصغيرة القابلة للتخلق بالخير والشر ممن يعلم أنه شرير أو فاسق فهو ظاهر سوء اختياره ولأن ترك النظر هنا

(٢) كه پلار يا نيکه د فسق او ليونتوب په وجه په سوء اختيار معروف وي او غيرکفو ته يې لور يا لمسی په نکاح ورکړې وي يا يې په مهر کې فاحش غبن کړی وي، نو نکاح صحت نه لري.^(٢٠)

(٣) سوء اختيار هغه مهال تحقق مومي چې پلار يا نيکه طمع کوونکی وي او تدبير ونه لري، يا د يادې نکاح له عقد څخه مخکې، د بلې لور يا لمسی داسې د نکاح عقد يې ترسره کړی وي چې مصلحت پکې نه وي.^(٢١)

د خيار بلوغ اثبات

نهمه ماده:



(١) د خيار بلوغ اثبات لپاره شاهدان اړين دي، يعنې کله چې يوه باکره انجلۍ بالغه شي، نو د بلوغ په مجلس کې به دوه يا تر دوه نارينه او دوه ښځينه شاهدان دروي، چې زما نکاح چې له فلانکي سره يې کړې ده فسخه مې کړه، که د بلوغ په وخت کې داسې څوک نه وي چې شاهد يې ونيسي، بيا به په ژبه وايي چې ما خپله نکاح فسخه کړه؛ خو کله چې پر شاهدانو برلاسې شي، بيا به شاهدان دروي او ورته وايي به چې زه اوس بالغه شوم او نکاح مې فسخه کړه، البته دغه فسخ د محکمې په حکم صورت مومي.^(٢٢)

(٢) که له پلار يا نيکه پرته له خپلوانو څخه يو، باکره صغيره په نکاح ورکړي، له بلوغ وروسته يې له زوج سره اختلاف راشي، انجلۍ ووايي: زه پرون بالغه شوم او فرقت مې اختيار کړی، زوج يې تکذيب وکړي، نو په دې صورت کې که له انجلۍ سره شاهدان نه وي، د زوج قول سره د يمين معتبر دی.^(٢٣)

مقطوع به فلا يعارضه ظهور ارادة مصلحة تفوق ذلك نظرا الى شفقة الابوة اذ ثم قال وقد وقع في اكثر الفتاوى في هذه المسئلة ان النكاح باطل فظاهره انه لم ينعقد، وفي الظهيرة يفرق بينهما ولم يقل انه باطل وهو الحق ولذا قال في الذخيرة في قولهم فالنكاح باطل اي يبطل انتهى كلام البحر، والمسئلة شهيرة. فتاوى الخيرية ص ٢٢. - ومنها اختيار الصغير أو الصغيرة بعد البلوغ في خيار البلوغ، وهذه الفرقة لا تقع إلا بتفريق القاضي. [بدائع الصنائع، ج ٢، ص ٣٣٦، ط: دار الكتب العلمية، بيروت]. (٢٠) - (قوله: مجانة وفسقا) ... وفي «المغرب»: الماجن الذي لا يبالي ما يصنع، وما قيل له، ومصدره المجون، والمجانة اسم منه، والفعل من باب طلب، اهـ وفي «شرح المجموع»: حتى لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعاً، اهـ. والحاصل: أن المانع هو كون الأب مشهوراً بسوء الاختيار قبل العقد، فإذا لم يكن مشهوراً بذلك ثم زوّج بنته، من فاسقٍ صبح، وإن تحقق بذلك أنه سقّ الاختيار واشهره عند الناس، فلوزّج بنتاً أخرى، من فاسقٍ لم يصبخ الثاني؛ لأنه كان مشهوراً بسوء الاختيار قبله، بخلاف العقد الأول لعدم وجود المانع قبله، ولو كان المانع مجرد تحقق سوء الاختيار بدون الاشهار لزم إحالة المسألة، أعني قولهم ولزم النكاح ولو بغيب فاحشٍ أو بغير كشفٍ إن كان الولي أباً أو جدّاً. ثم اعلم أن ما مرّ عن «النوازل» من أن النكاح باطلٌ معناه: أنه سيبطل، كما في «الذخيرة»: لأن المسألة مفروضة فيما إذا لم ترض البنت بعد ما كبرت، كما صرح به في «الغانية» و«الذخيرة» وغيرهما، وعليه يحمل ما في «القنية»: زوّج بنته الصغيرة من رجلٍ ظنّه حرّاً الأصل وكان معتقاً، فهو باطلٌ بالاتفاق، اهـ. [رد المحتار، ج ٣، ص ٦٧، ط: ايج ايم سعيد، كراتشي].

(٢١) المرجع السابق

(٢٢) - (واستفيد من بطلانه بسكوته، أنه لا يمتد إلى آخر المجلس، وعلى هذا قالوا: ينبغي أن يبطل مع رؤية الدّم فإن رآته ليلاً تطلب بلسانها، فتقول: فسخت نكاحي، وتشهد إذا أصبحت، وتقول: رأيت الدّم الآن، وقيل لمحمد رحمه الله تعالى: كيف يصبغ وهو كذّابٌ، وإنما أدركت قبل هذا، فقال: لا تصبغ في الإسناد فجازلها أن تكذب كي لا يبطل حقها، ثم إذا اختارت وأشهدت ولم تقدم إلى القاضي الشّهروالشّهيرين فهي على خيارها، كخيار العيب). [البحر الرائق، ج ٣، ص ١٣١، ط: دار الكتب الشرعية والأدبية، كويت].

- (وإن رآته بالليل تختار بلسانها، فتقول: فسخت نكاحي، وتشهد إذا أصبحت. وتقول: رأيت الدّم الآن، فإن قالت: الحمد لله اخترت فهي على خيارها. وإن بعثت خادمها حين حاضت فدعا شهوذاً فلم يقدر عليهم، وهي في مكان منقطع لزمها النكاح ولم تعذر، ولو سألت عن اسم الزّوج أو عن المهر المسمّى أو سلّمت على الشّهود بطل خيارها، ولو اختارت وأشهدت ولم تتقدّم إلى القاضي لشهرين فهي على خيارها، كخيار العيب). [تبيين الحقائق، ج ٥، ص ٣٣٠، ط: مكتبته أشرفيه، كويت].

- (قوله: وتشهد إلخ) ... وفي «جامع الفصولين» فإن قالوا: متى بلغت؟ تقول: كما بلغت نقضته، لا تزيد على هذا؛ فإنها لو قالت: بلغت قبل هذا ونقضته حين بلغت لا تصبغ، والإشهاد لا يشترط لاختيارها نفسها. لكن شرط لإثباته بينة ليسقط اليمين عنها، وتعليقها على اختيارها نفسها، كتعليق الشّفع على الشّفعة. فإن قالت للقاضي: اخترت نفسي حين بلغت صديقت مع اليمين. ولو قالت: بلغت أمم وطلبت الفرقة لا يقبل وتحتاج إلى البينة. وكذا الشّفع لو قال: طلبت حين علمتُ فالقول له، ولو قال: علمتُ أمم وطلبت، لا يقبل بلا بينة. اهـ. [رد المحتار، ج ٣، ص ٧٥، ط: ايج ايم سعيد، كراتشي].

(٢٣) (صغيرة زوجها غير الأب والجد، فاخصمت مع زوجها بعد البلوغ، وهي بكر، فقالت: اخترت الفرقة حين بلغت وكذبها الزوج لا يقبل قولها إلا ببينة. " [الفتاوى الثّقروية، ج ١، ص ٤٣١، ط: مكتبته سلطانية، كويت].

(۳) که زوجه، د قاضي په وړاندې ووايي، زه اوس بالغه شوم او نکاح مې فسخه کړه، په دې صورت کې يې تصديق کېږي، شاهدانو او يمین ته اړتیا نه شته. (۲۴)

(۴) که زوجه ووايي: کله چې زه بالغه شوم، ما نکاح فسخه کړه، نو په دې صورت کې د فسخې د اثبات لپاره به زوجه شاهدان وړاندې کوي که شاهدان ونه لري نو زوج به قسم اداء کوي. (۲۵)

(۵) که له پلار يا نیکه پرته له خپلوانو څخه يو، باکره صغیره په نکاح ورکړي وي خو انجلۍ له بلوغ وړاندې له خپلې نیکه څخه ناسته وي، نو کله چې له بلوغ وروسته له خپلې نکاح څخه خبره شي، هغې ته خيار بلوغ شته؛ که څه هم له بلوغ وروسته زيات وخت تېر شوی وي. (۲۶)



په خيار بلوغ سره د نکاح د فسخه کولو شرط

لسمه ماده:

د خيار بلوغ په سبب د نکاح عقد د فسخ کولو لپاره، د قاضي قضاء شرط ده او د قاضي له قضاء پرته نکاح نه شي فسخه کېدلی. (۲۷)

درېم فصل

د رضاعت په سبب تفريق

رضاعت

یوولسمه ماده:

(۱) کله چې يوه ښځه (مرضعه)، زوجینو ته خبر ورکړي چې تاسې دواړه په خپلو کې رضاعي (تي رودونکې) خور او ورو او يا عمه او وراره یاست يا دې ته ورته، مېرمن او مېړه دواړه د یادې ښځې خبر تصديق کړي يا مېړه يې تصديق او مېرمن يې تکذيب وکړي، په دې صورت کې مېرمنه پر مېړه حرامه شوه او که مېرمن، يې تصديق او مېړه يې تکذيب وکړي، نکاح يې پر خپل حال پاتې ده. البته مېرمن به خپل مېړه ته په دې قسم ورکوي، چې زه ستا رضاعي (تي رودونکې) خور يا عمه نه يم؟ که مېړه له قسم څخه انکار وکړ، قاضي دې، د دواړو ترمنځ په تفريق حکم وکړي. (۲۸)

- (وقيد بالبرکة البالغة؛ فإن الضمير عائد إليها احتراماً عن الصغيرة التي زوجها غير الأب والجدة إذا قالت بعد البلوغ: كنت رددت حين بلغني الخبر وكذبها الزوج، فإن القول قوله؛ لأن الملك ثابت عليها، فهي بما قالت تريد إبطال الملك الثابت عليها، فكانت مدعية صورة فلا يقبل منها إسناد الفسخ، حتى لو قالت عند القاضي: أدركت الآن وفسخت صبح). [البحر الرائق، ج ۳، ص ۱۲۶، ط: دار الكتب الشرعية والأدبية، الكويت].

- (ومنها اختيار الصغير أو الصغيرة بعد البلوغ في خيار البلوغ، وهذه الفرقة لا تقع إلا بتفريق القاضي). [بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۳۳۶، ط: دار الكتب العلمية، بيروت]. (۲۴) المراجع السابقة.

(۲۵) المراجع السابقة.

(۲۶) (لكن (لهما) أي: لصغير وصغيرة وملحق بهما (خيار الفسخ) ولو بعد الدخول (بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده) لقصور الشفقة).

[التنوير والنور على هامش رد المحتار، ج ۳، ص ۶۹، ط: إيج ايم سعيد، كراتشي].

(۲۷) (لكن (لهما) أي: لصغير وصغيرة وملحق بهما (خيار الفسخ) ولو بعد الدخول (بالبلوغ أو العلم بالنكاح بعده)... (بشرط القضاء) للفسخ

(قوله: بشرط القضاء) أي: لأن في أصله ضعفاً، فيتوقف عليه كالزجوع في الهبة... (قوله: للفسخ) أي: هذا المشرط إنما هو لفسخ لا لثبوت الاختيار. وحاصله: أنه إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجدة، فلهما الخيار بالبلوغ أو العلم به، فإن اختار الفسخ لا يثبت الفسخ إلا بشرط القضاء.

[التنوير والنور رد المحتار، ج ۳، ص ۶۹، ط: إيج ايم سعيد، كراتشي].

(۲۸) - (لوشهدت امرأة بأنها أرضعتها... ولو صدقها قعد النكاح، وعليه مهر المثل إن دخل بها، وإن صدقها دون المرأة حرمت عليه، وإن صدقها دون الزوج فهي امرأته، ولها تحلف الزوج أنها ليست أخته من الرضاع، فإن نكل فرق بينهما). (الفتاوى السراجية، ص ۲۰۹، باب الرضاع، ط: مكتبة معروفية، كويت].

- (الرضاع يظهر بأحد أمرين أحدهما الإقرار، والثاني البيّنة، كذا في «البدائع»). [الفتاوى الهندية، ج ۱، ص ۳۴۷، كتاب الرضاع، ط: مكتبة حبيب، كويت].

- (فيحرم منه) أي: بسببه (ما يحرم من النسب) رواه الشيخان...

(قوله: ما يحرم من النسب) معناه: أن الحرمة بسبب الرضاع معتبرة بحرمة النسب، فشمّل زوجة الابن والأب من الرضاع؛ لأنها حرام بسبب النسب، فكذا بسبب الرضاع، وهو قول أكثر أهل العلم، كذا في «المبسوط» «بحر»]. [التنوير والنور رد المحتار، ج ۳، ص ۲۱۳، ط: إيج ايم سعيد، كراتشي].

(۳) که دوه عادل سړي، يا يو عادل سړی او دوه عادلې ښځې شاهدي اداء کړي، چې دغه ښځه؛ د دغه زوج رضاعي (تي رودونکې) خور، خاله، عمه، مور، انا يا ورېره ده، په دې صورت کې دوى دواړه يو پر بل باندې حرام دي او قاضي دې، د دواړو ترمنځ په تفريق حکم وکړي. (۲۹)

(۴) په رضاعت کې د شاهدانو شاهدي، د ښځې په دعوى پورې موقوفه نه ده، بلکې د ښځې له دعوى او غوښتنې پرته هم شاهدان خپله شاهدي اداء کولای شي. (۳۰)

(۵) که شاهدانو، د يوې ښځې په حضور کې په شرعي طريقې سره شاهدي اداء کړه، چې مثلاً ستا مېر، ستا رضاعي ورور کېږي، مېر يې انکار وکړي او د شهادت له اداء کولو وروسته، شاهدان مړه يا غائب شي، په دې صورت کې مېرمنې ته خاير نه دی چې له زوج سره ژوند وکړي، بلکې په هره ممکنه لاره چې کېدلى شي، ځان دې ورڅخه خلاص کړي. (۳۱)

**له يوې ښځې څخه تې رودلي مېر او مېرمن
دوولسمه ماده:**

(۱) که يوه ښځه ووايي چې ما دغه مېر او مېرمنې ته تې ورکړى دى، لاندې صورتونه او حکمونه لري:

- ۱- که زوجينو تصديق کړه، او دخول صورت موندلى نه وي نکاح فاسده او د ښځې لپاره مهر نه شته.
- ۲- که زوجينو تصديق کړه او دخول صورت موندلى وي نکاح ختمه او د ښځې لپاره مهر مثل دى.
- ۳- که زوجينو تکذيب کړه او دغه مخبره مرضعه ښځه عادلې وي، نو نکاح ختمه نه ده او مېر لپاره اختيار دى چې نکاح برقراره وساتي او يا مفارقه وکړي البته مفارقه غوره ده، که مېر مفارقت راوستو، او دخول صورت موندلى نه و، د مېر لپاره غوره ده چې نيم مهر مېرمنې

- (إذا أرضعت صبياً هذه الصبية على زوجها، وعلى أبنائها وأولاده، وعلى إباء المرضعة وأولادها. الأصل: أن أقرباء المرضعة وأقرباء زوجها أقرباء الرضيع). [الفتاوى المراجعة، ص ۲۰۷، كتاب النكاح، باب الرضاع، ط: مكتبة معروفة، كويته].

(۲۹) - (و الرضاع حجة المال) وهي شهادة عدلين أو عدلٍ وعدلتان، لكن لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي لتضمينها حق العبد. (قوله: وهي شهادة عدلين [إخ] أي: من الرجال. و أفاد أنه لا يثبت بخير الواحد امرأة كان أورجلاً قبل العقد أو بعده... (قوله: وعدلتان) أي: ولو إحداهما... (قوله: لتضمينها) أي: الشهادة حق العبد، أي: إبطال حقه وهو حل التمتع فلا بد من القضاء أي: إن لم توجد المتاركة، لما في «التهر»: الحاصل: أن المنصب عندنا كما قال الزلعي في اللعان أن النكاح لا يرتفع بحرمة الرضاع والمصاهرة بل يفسد، حتى لو وطئها قبل التفريق لا يجب عليه الحد أشبه الأمر ولم يشته، نص عليه في «الأصل». وفي الفاسد لا بد من تفريق القاضي أو المتاركة بالقول في المدخول بها، وفي غيرها يكتفى بالمفارقة بالأبدان، كما مر، اه).

[التنوير والبرورد المختار، ج ۳، ص ۲۲۴، ط: ايج ايم سعيد، كرتشي].

- (وأما البينة: فهي أن يشهد على الرضاع رجلان أو رجلٌ وامرأتان، ولا يقبل على الرضاع أقل من ذلك، ولا شهادة النساء بانفرادهن).

[بدائع الصنائع، ج ۴، ص ۱۴، ط: دار الكتب العلمية، بيروت].

- (ولا يقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين عدول، كذا في «المحيط» ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي، كذا في «التهر الفائق»).

[الفتاوى الهندية، ج ۱، ص ۳۴۷، ط: مكتبة حبيبيه، كويته].

(۳۰) - (وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة: الظاهر لا) لتضمينها حرمة الفرج، وهي من حقوقه تعالى. (قوله: الظاهر لا)، كذا استظهره في «البحر» مستنداً لمسألة الطلاق المذكورة، ومثلها الشهادة بعقوبة الأئمة ونحوها من المسائل الأربعة عشر التي تقبل الشهادة فيها حسبة بلا دعوى، وهي مذكورة في قضاء «الشهاب» فتزاد هذه عليها). [التنوير، والدر، ورد المختار، باب الرضاع، ج ۳، ص ۲۲۵، ط: ايج ايم سعيد، كرتشي].

- (وهل يتوقف على دعوى المرأة الظاهر عدمه، كما في الشهادة بطلاقها، فإنه يتضمن حرمة الفرج وهي من حقوقه تعالى).

[البحر الرائق، ج ۳، ص ۲۵۱، ط: دار الكتب الشرعية والأدبية، كويته].

(۳۱) - (ولو شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلاثاً وهو يجحد، ثم ماتا أو غابا قبل الشهادة عند القاضي لا يسعها المقام معه ولا قتله، به يفتى، ولا التزوج بأخر. وقيل: لها التزوج ديانة، «شرح وهبانية».

(قوله: لا يسعها المقام معه): لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع، فكذا إذا أقامت عندها، «خاتمة». [التنوير والبرورد المختار، ج ۳، ص ۲۲۵، ط: ايج ايم سعيد، كرتشي].

- (ولو شهد عندها عدلان على إرضاع بينهما، وهو يجحد ثم ماتا أو غابا قبل الشهادة عند القاضي، لا يسعها المقام معه، كما لو شهدا بطلاقها الثلاث كذلك، وتماهه في «شرح المنظومة» والله سبحانه وتعالى أعلم). [البحر الرائق، ج ۳، ص ۲۵۱، دار الكتب الشرعية والأدبية، كويته].

ته ورکړي او د ښځې لپاره غوره ده چې هېڅ شی وانهخلي. او که دخول صورت موندلی وي، نو د مېړه لپاره غوره ده چې مهر، نفقه او سکنی پوره ورکړي او مېرمنې ته غوره ده چې له مهر مثل او مهر مسمی څخه اقل واخلي، نفقه او سکنی پرېږدي. (۳۲)

څلورم فصل

د حرمت مصاهرت په سبب تفریق

حرمت مصاهرت

دیارلسمه ماده:



(۱) که یو سړي یا یوې ښځې د خپلې منکوحې یا د زوج له اصولو یا فروعو سره زنا کړې وي او یا یې وکړي یا ورسره هغه اعمال ترسره کړي چې له امله یې د حنفی فقهې له تشریحاتو سره سم، حرمت مصاهرت را منځته کېږي، د زوجینو د تفریق سبب ګرځي.
(۲) د مصاهرت تعریف او د حرمت مصاهرت اړونده نور حکمونه او مسائل په اړونده طرز العمل کې تنظیمېږي.

د مېړه د اصولو او فروعو لخوا د مېرمنې د لمس کولو حکم

څوارلسمه ماده:

که یوه مېرمن دعوی وکړي چې، د مېړه اصولو او یا فروعو زه په شهوت سره لمس کړم، یا یې ښکل کړم، په دې صورت کې دې، قاضي د هغې له مېړه څخه پوښتنه وکړي چې ته دغه خبره منې که یې ردوي؟ که یې ومنله، قاضي د هغوی ترمنځ په تفریق حکم کوي او که مېړه رد کړه، قاضي دې له مېرمنې څخه شاهدان وغواړي، که مېرمنې په شرعي طریقې سره شاهدان حاضر او خپله دعوه یې ثابته کړه، قاضي به د هغوی ترمنځ په تفریق حکم کوي، که شاهدان یې په شرعي طریقې سره حاضر نه کړل، قاضي د دعوی کوونکې مېرمنې مېړه ته قسم ورکوي، که مېړه د قسم له اداء کولو څخه نکول (انکار) وکړ، نو قاضي به د دوی ترمنځ په تفریق حکم کوي او که قسم یې اداء کړ، قاضي دې، د دوی موضوع له محکمې څخه بهر کړي. (۳۳)

(۳۲) [تنبیه] في «الهندية»: تزوج امرأة فقالت امرأة: ارضعتكما فهو على أربعة أوجه: إن صنتها فسد النكاح ولا مهران لم يدخل، وإن كتبها وهي عدلة فالتزوة المفارقة والأفضل له إعطاء نصف المهر ولم يدخل، والأفضل لها أن لا تأخذ شيئاً، ولو دخل فالأفضل كماله والنفقة والمسكن، والأفضل لها أخذ الأقل من مهر المثل والمسكن لا النفقة والمسكن ويسعه المقام معها، وكذا لو شهد غير عدول أو امرأتان أو رجل وامرأة، وإن صنتها الرجل وكذبها فسد النكاح والمهر بحاله وإن بالعكس لا يفسد ولها أن تحلف ويفرق إذا نكل، اهـ. [رد المحتار، ج ۳، ص ۲۲۴، ط: إيج ايم سعيد، كراتشي].

(۳۳) - (ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها). [هداية، ج ۲، ص ۲۸۹، ط: مكتبة رشيدية، كويته]
(وأطلق في اللبس والنظر بشهوة، فأفاد أنه لا فرق بين الغنى والخطأ، والنسيان، والإكراه، حتى لو أيقظ زوجته ليجماعها فوصلت يده إلى بنته منها ففرصها بشهوة وهي تُشتهي يظن أنها حرمت عليه أتم حرمة مؤبدة، ولك أن تصوّرهما من جانبها بأن أيقظته هي لذلك ففرصت ابنه من غيرها، كذا في «فتح القدير». [البحر الرائق، ج ۸، ص ۴۳، ط: دار الكتب الشرعية والأدبية، كويته].

(۳۴) (رجل قبل امرأة أبيه بشهوة أو قبل الأب امرأة ابنه بشهوة وهي مكروهة وأنكر الزوج أن يكون بشهوة فالقول قول الزوج، وإن صدقه الزوج وقعت الفرقة ويجب المهر على الزوج ويرجع بذلك على الذي فعل إن تعمد الفاعل الفساد، وإن لم يتعمد: لا يرجع وفي الوطء لا يرجع وإن تعمد بالوطء الفساد؛ لأنه وجب الحد والمال مع الحد لا يجتمع). [الفتاوى الهندية (۱/ ۲۶۶)، ط: مكتبة حبيبيه، كويته]

- (وإن ادعت الشهوة في تقبيله أو تقبيلها ابنه (وأنكرها الرجل فهو مصنق) لا هي (إلا أن يقوم إلها منشراً) أنه (فيعانقها) لقربة كذبه أو يأخذ ثوبا (أو يركب معها) أو يمسها على الفرج أو يمسها على الفم. قاله الحدادي. وفي «الفتح»: يترأى إلحاق الخنثين بالفم. وفي «الخلاصة» قيل له: ما فعلت بأمر أمرك؟ فقال: جامعها ثبتت الحرمة، ولا يصنق أنه كتب ولو هازلًا. (وتقبل الشهادة على الإقرار باللمس والتقبيل عن شهوة وكذا) تقبل (على نفس اللبس والتقبيل) والنظر إلى ذكره أو فرجها (عن شهوة في المختار) «تجنيم»: لأن الشهوة مما يوقف عليها في الجملة بانتشار آثاره.

(قوله: وإن ادعت الشهوة في تقبيله) أي: ادعت الزوجة أنه قبل أحد أصولها أو فروعها بشهوة أو أن أحد أصولها أو فروعها قبله بشهوة... (قوله: فهو مصنق): لأنه ينكر ثبوت الحرمة والقول للمنكر، وهذا ذكره في «الذخيرة» في الممن لا في التقبيل، كما فعل الشارح، فإنه مخالف لما مضى عليه المصنق أولاً من أنه في التقبيل يفي بالحرمة ما لم يظهر عدم الشهوة، وقدّمنا عن «الذخيرة» نقل الخلاف في ذلك فما هنا مبني على ما في بيوع «العيون»... (قوله: وفي الفتح إلخ) قال فيه: والحاصل: أنه إذا أقرب بالنظر وأنكر الشهوة صنق بلا خلاف، وفي المباشرة لا يصنق بلا خلاف فيما أعلم، وفي التقبيل اختلف فيه: قيل: لا يصنق؛ لأنه لا يكون إلا عن شهوة غالباً، فلا يقبل إلا أن يظهر خلافه بالانتشار ونحوه. وقيل: يقبل. وقيل: بالتفصيل بين كونه على الرأس، والجهة، والخذ فيصنق أو على الفم فلا، والأرجح هذا إلا أن الخد يترأى إلحاقه بالفم، اهـ.

[التنوير والبرود المحتار، ج ۳، ص ۳۷-۳۸، ط: إيج ايم سعيد، كراتشي].

پنځم فصل د مفقودوالي په سبب تفریق

د مېړه مفقودوالي

پنځلسمه ماده:

(۱) که مفقود، د مفقود في الحروب او مظان الهلاك له جملې څخه وي او داسې قرائن موجود وي چې د هغه مرگ ثابتوي او يا دومره اوږده موده تېره شوې وي چې د قاضي غالب گمان د مرگ پرې راځي. د عاليقدر اميرالمؤمنين حفظه الله تعالى د ۱۴۴۱/۴/۱۰ هـ ق نيټې (۵۳/۴۳) گڼه فرمان مطابق دي د اړوندې محكمې قاضي د مفقود په مرگ حكم صادر كړي او د مفقود زوجه ته يې د وفات د عدت په تېرولو امر وكړي او دا حكم دې وكړي چې له ياد عدت وروسته د مفقود زوجه كولاى شي چې له بل زوج سره نكاح وكړي. (۴۰)

(۲) که مفقود، د مفقود في الحروب او مظان الهلاك له جملې څخه نه وي بيا دي د حنفي فقه مطابق د مفقود مېړه دومره موده انتظار تېروي چې د مفقود مرگ يې يقيني شي او د ده د قرن خلك (همزولي) ټول وفات شي. (۳۶)

د مفقود او د هغه د مېړمنې د تفریق اړوند پړاوونه

شپاړسمه ماده:

د مفقود او د هغه د مېړمنې د تفریق په مسئله کې د احتياط په خاطر لاندې پړاوونه په پام کې نيول لازمي دي:

- (حكيم الامت مولانا شاه محمد اشرف علي تھانوي (رحمه الله تعالى) په حيله ناجزه کې فرمايي، قاضي به دوسيه د محكمې څخه خارجې كړي نه به د نكاح په فسخه كولو حكم كوي اونه په اثبات د نكاح، اود دغه بشې لپاره د دغه خاوند سره اوسېدل جائز نه دي، په طريقه د خلع دي خان خلاص كړي، كه يې خلع نه كول بيا به هم بشې وده سړي ته پر خپل خان باندې قدرت نه وركوي، او كه د خاوند پر دغه يقين ويا يې غالب گمان و چې دغه حرمت به راغلی وي، نو بيا د دغه خاوند اوسېدل د دغه بشې سره حرام دي). [د پوره تفصيل لپاره دې، الحيلة الناجزه وكتل شي، ص ۸۷-۹۱، ط: كراتشي].

(۳۵) د مفقودينو د موضوع په هکله د اسلامي امارت د مشرتابه مقام فرمان:

محاکمونه ډېر وختونه د مفقود مسأله راجع کيږي قاضيان په کې متردد وي چې پر کوم قول د فقهاؤ فيصله وکړي ځکه چې په نوموړې مسئله کې د فقهاؤ مختلف اقوال راغلي دي نو د دې لپاره چې د قاضيانو تردد پورته شي قاضيان دي د مفقود د زوجې په هکله که کومه قضيه ورته راجع شي او مفقود د مفقود في الحروب و مظان الهلاك له جملې څخه وي، محکمه دي د احنافو علماؤ د قول مطابق چې قرآنې د مرگ ظاهري وي او دومره اوږده موده تېره شوې وي چې د قاضي غالب گمان د مرگ په راځي، حکم دي په مرگ د مفقود صادر کړي له هغه وروسته دي زوجې د مفقود ته د وفات د عدې په تېرولو امر وکړي، له هغه وروسته دي د بل زوج سره د نكاح اجازه ورکړي، البته چون دا مسئله د يو چا په مرگ باندې حکم کول دي د ډير احتياط په خاطر دي لاندې مراحل هم په نظر کې ونيول شي په نوموړې قضيه کې دي ټول محاکم د محاکمود عالي ادارې سره جريان شريکوي په نوموړې قضيه کې چې د عالي ادارې کوم شرائط دي هغه دي په پام کې ونيسي او د عالي ادارې تر تائيد وروسته دي فيصله مشرتابه ته راجع شي، د مشرتابه تر تائيد وروسته دي نافذ شي. والسلام اميرالمؤمنين شيخ القرآن والحديث مولوي هبة الله اخنذاده.

- قال وإذا رفع إلى القاضي حكم الحاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. الهداية شرح البداية (۱۴۱/۳) ط اميرحمزه.

- قال: (فإن مضى له من العهر ما لا يعيش أقر أنه حكم بموته) وهو الأفيق على قول أبي حنيفة لإختلاف الأعمار باختلاف الزمان. [الاختيار لتعليق المختار] ج ۳ ص ۳۸ الناشر: مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتها دارالكتب العلمية - بيروت، وغيرها).

- وفي ظاهر الرواية يُقْتَرُ بِمَوْتِ الْأَقْرَبِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ أَقْرَبِهِ حَيًّا حُكِمَ بِمَوْتِهِ لَنْ مَا تَقَعُ الْحَاجَةُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ فَطَرِيقُهُ فِي الشَّرْحِ الرَّجُوعُ إِلَى أَمْثَالِهِ كَقِيمِ الْمُتَلَفَاتِ وَمَنْ مِثْلِ الْبَسَاءِ، وَتَقَاوُهُ بَعْدَ مَوْتِ جَمِيعِ أَقْرَبِهِ تَأْوِيلُ بِنَاءِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الظَّاهِرِ دُونَ النَّاسِ،

- فظاهر الرواية وهو المنهوب أنه مقرب موت الاقربان في السن لان من النوادر أن يعيش الانسان بعد موت أقرانه فلا ينبغي الحكم عليه، فإذا بقي منهم واحد لا يحكم بموته.

واختلفوا في المراد بموت أقرانه ف قيل من جميع البلاد، وقيل من بلده وهو الاصح، [البحر الرائق شرح كتر الدقائق - ج ۵ ص ۲۷۶ دارالكتب العلمية بيروت - لبنان]

- وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَجْتَبَى وَيَحْكَمُ الْقَرَبُ الظَّاهِرَةُ الدَّالَّةُ عَلَى مَوْتِهِ وَعَلَى هَذَا يُنْتَقَى عَلَى مَا فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى خَيْثُ قَالَ: وَإِذَا قُبِدَ فِي الْمَمْلَكَةِ فَمَوْتُهُ غَالِبٌ فَيَحْكَمُ بِهِ، كَمَا إِذَا قُبِدَ فِي وَفَتْ الْمَلَاقَةُ مَعَ الْعَدُوِّ أَوْ مَعَ قَطَاعِ الطَّرِيقِ، أَوْ سَافَرَ عَلَى الْمَرَضِ الْغَالِبِ مَلَكَهُ، أَوْ كَانَ مَسْفَرَةً فِي الْبَحْرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ حُكِمَ بِمَوْتِهِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي هَذِهِ الْحَالَاتِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ اخْتِمَالَيْنِ، وَاخْتِمَالُ مَوْتِهِ نَاسِئٌ عَنْ دَلِيلٍ لَا اخْتِمَالَ حَيَاتِهِ؛ لَنْ هَذَا الْاِخْتِمَالُ كَاخْتِمَالِ مَا إِذَا بَلَغَ الْمَفْقُودُ مَقْدَارَ مَا لَا يَعِيشُ عَلَى حَسَبِ مَا اخْتَلَفُوا فِي الْمَقْدَارِ نَقْلًا مِنْ الْغَنِيِّ اهـ مَا فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى. [الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ۲۹۷/۴ الناشر: دار الفكر - بيروت]

وَأَفْقَى بِهِ بَعْضُ مُشَافِحٍ مَشَافِحًا وَقَالَ إِنَّهُ أَفْقَى بِهِ قَاضِي زَادَهُ صَاحِبُ بَحْرِ الْفَتَاوَى، لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَضِيِّ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ لَا بِمَجَرَّدِ فَقْدِهِ عِنْدَ مَلَاقَةِ الْعَدُوِّ أَوْ مَسْفَرِهِ الْبَحْرَ وَنَحْوَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ مَلِكًا عَظِيمًا فَإِنَّهُ إِذَا بَقِيَ حَيًّا تَشْغُرُ حَيَاتُهُ، فَلِذَا قُلْنَا إِنَّ هَذَا مِنْبِئٌ عَلَى مَا قَالَهُ الرَّئِيسُ تَأَمَّلْ

(۳۶) المرجع السابق.

۱- د مقفود مېرمن، که له مقفود سره نکاح ختمول او له بل چا سره نکاح کول غواړي، مکلفه ده چې خپله غوښتنه په عريضه کولو سره محکمې ته وړاندې او خپله نکاح او د مېرمنه مقفودیت په شهودو سره ثابت کړي.

۲- قاضي مکلف دی چې د مقفود د مېرمنې له عريضې کولو وروسته، د دې اصولنامې د پنځلسمې مادې د صورتونو په پام کې نیولو سره، د یاد مقفود په هکله بشپړه څېړنه وکړي. (۳۷)

۳- په یاده قضیه کې د درې گونو محکمو د پړاوونو تېرول لازمي دي.

۴- که د سترې محکمې له خوا په یاده قضیه کې شوې پرېکړه تأیید شوه، د سترې محکمې قاضي القضاات مکلف دی له تأیید وروسته، پرېکړه د عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی حضور ته راجع کړي.

۵- یاده پرېکړه، د عالیقدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له تأیید وروسته نافذېږي.

د وفات عدت تېرول

اوولسمه ماده:

(۱) د دې اصولنامې په پنځلسمه ماده کې له یاد شوي حکم او په شپاړسمه ماده کې د درج شويو پړاوونو له تېرولو وروسته، د مقفود مېرمن مکلفه ده چې د وفات عدت (څلور میاشتې او لس ورځې) موده، د حنفي فقهې له حکمونو سره سم په پوره ډول تېره کړي. (۳۸)

(۲) د دې مادې په (۱) فقره کې د یاد عدت له تېرولو وروسته، د یاد مقفود مېرمن کولی شي له بل چا سره نکاح وکړي. (۳۹)

شپږم فصل

د خلعي او غیابت په سبب تفریق

د مېرمنې له خوا خلعي ته د مېرمنه راضي کول

اتلسمه ماده:

(۱) مېرمنه کولی شي چې د خپل مېرمنه په خوښه له هغه څخه د خلعي په طریقه ځان جلا کړي. (۴۰)

(۲) خلغ کول په هر اندازه مال سره چې زوجین پرې راضي شول صحیح ده، البته د خلعي بدل له مهر مسمی څخه زیات اخیستل، په هغه صورت کې چې مېرمنه ناشزه نه وي، مناسب نه ده. (۴۱)

(۳) خلغ کول طلاق بائن دی. (۴۲)

خلعي او طلاق ته د مېرمنه نه رضایت اړونده حکمونه

نولسمه ماده:

(۳۷) ثُمَّ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ نَظَرُ فِيهَا وَكَتَبَ إِلَى مُؤَيَّدِهِ الَّذِي خَرَجَ إِلَيْهِ. (المبوتة ۲/ ۳۰)

(۳۸) - فَإِذَا حُكِمَ بِمَوْتِهِ وَجَبَ عَلَى أَمْرَاتِهِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنْ وَقْتِ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ. [الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (۱/ ۳۶۱) الناشر: المطبعة الخيرية]

- وإذا حكم بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت [الهداية في شرح بداية المبتدي ج ۲ ص ۱۴۸ الناشر: دار الفكر - بيروت - لبنان]

(۳۹) ثم تترج من شاءت لأن عمر رضي الله عنه هكنا قضى في النبي امهواه الجن بالمدينة وكفى به إماما. (الهداية شرح البداية - المكتبة الإسلامية (۲/ ۱۸۱))

(۴۰) (قال): والخلع جائز عند السلطان وغيره؛ لأنه عقد يعتمد التراضي كسائر العقود، وهو بمنزلة الطلاق بعوض، وللزوج ولاية إيقاع الطلاق، ولها ولاية التزام العوض، فلا معنى لاشتراط حضرة السلطان في هذا العقد. (المبسوط للمرخمي (۱/ ۱۷۳))

- (وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال، يخلعها به لقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة، ولزمها المال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الخلع تطليقة بائنة». [الهداية، ج ۲، ص ۱۳، باب الخلع، ط: مكتبة رشيدية، كويت].

- قوله (الطلاق لمن أخذ بالمساق) كناية عن ملك المتعة. (حاشية ابن عابدين - الفكر (۳/ ۲۴۲))

(۴۱) وهو أن تفتدي المرأة نفسها بمال يخلعها به، فإذا فعلا لزمها المال ووقعت تطليقة بائنة، ويكره أن يأخذ منها شيئا إن كان هو الناشر، وإن كانت هي الناشزة كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاهما، وإن أخذ منها أكثر مما أعطاهما حل له. (الاختيار لتعليق المختار (۳/ ۱۵۶))

(۴۲) قال - رحمه الله - (الواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن) يعني الواقع بالخلع وبالطلاق الصريح إذا كان بعوض يكون بائنا. (تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلي (ج ۲ ص ۲۶۸))

(۱) که یوه مېرمنه د مېړه د غیرمفقود غائبوالي او یا د نقې د نه ورکولو له امله له قاضي څخه د تفریق غوښتنه وکړي، قاضي د تفریق حکم نه شي کولی. (۴۳)

(۲) د غیرمفقود غائب شخص د مېرمنې د نقې، سکنې او د هغې اړونده نور حکمونه او مسائل په اړوند طرز العمل کې تنظیمېږي.

د قاضي له تفریق څخه وروسته د مفقود مېړه راتلل

شلمه ماده:

(۱) که په تفریق باندې له حکم کولو څخه وروسته مفقود راشي او مېرمن یې بل مېړه کړی وي نو د دوهم مېړه او یادې مېرمنې ترمنځ به تفریق کېږي او ښځه د لومړي مېړه ده. البته قاضي به لومړي مېړه ته اختیار ورکړي چې دغه ښځه ساتي، که طلاق ورکوي او که د طرفینو د رضا په صورت کې خلع ورسره کوي. (۴۴)

(۲) د دې مادې په (۱) فقره کې یاد شوی لومړی مېړه که یاده مېرمن له ځان سره ساتل غواړي، نو د عدت تر ختمیدو پورې به ورته نږدېکت نه کوي^(۴۵) او که لومړی مېړه، یاده مېرمن له ځان سره ساتل نه غواړي نو په دې صورت کې به طلاق ورکوي او یاده مېرمن به عدت تېروي او له عدت تېرولو څخه وروسته به له دوهم مېړه سره (چاسره یې چې نکاح کړې وه) د نکاح نوی عقد وکړي. (۲) د مفقود او غیرمفقود غائب مېړه اړونده نور حکمونه او مسائل په اړوند طرز العمل کې تنظیمېږي.

له بل شخص سره د واده په صورت کې د پیدا شوي مفقود مېړه د مېرمنې د مهر حکم

یوویستمه ماده:

که پیدا شوي مفقود ته د ده مېرمنه واپس کړل شي په هغه صورت کې یاده مېرمن له دوهم مېړه څخه د مهر مستحقه ګرځي چې د دوهم مېړه له خوا هغې سره دخول او یا خلوت صحیح صورت موندلی وي. (۴۷)

اووم فصل

د متعنت والي په سبب تفریق

له ظالم مېړه څخه خلع کول یا طلاق اخیستل

دوه ویستمه ماده:

(۵۰) (ولا یفرق بینهما بعجزه عنها) بأنواعها الثلاثة (ولا یعدم ایفائه) لو غابا (حقها ولو موسرا) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وتضررها بغيبته، ولو قضی به حنفي لم ینفذ).

الدرا مختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۵۹۰/۳)

(۴۴) وقد صرح رجوعه عنه إلى قول علي - رضي الله عنه - فإنه كان يقول ترد إلى زوجها الأول، ويفرق بينهما وبين الآخر، ولها المهر بما استحل من فرجها، ولا يقرها الأول حتى تنقضي عدتها من الآخر وهذا كان يأخذ إبراهيم - رحمه الله - فيقول: قول علي - رضي الله عنه - أحب إلي من قول عمر - رضي الله عنه -، وبه تأخذ أيضا؛ لأنه تبيين أنها تزوجت، وهي منكوبة ومنكوبة الغير ليست من المحلات بل هي من المحرمات في حق سائر الناس كما قال الله تعالى: (والمحصنات من النساء) [النساء: ۲۴] فكيف يستقيم تركها مع الثاني، وإذا اختار الأول المهر، ولكن يكون النكاح منعقدا بينهما فكيف يستقيم دفع المهر إلى الأول، وهو يدل بضعها فيكون مملوكا لها دون زوجها كالمكوبة إذا وطئت بشبهة، فعرفنا أن الصحيح أنها زوجة الأول، ولكن لا يقرها لكونها معتدة لغيره كالمكوبة إذا وطئت بالشبهة. المبسوط للمرخمي (ج ۱ ص ۳۷) الناشر: دار المعرفة - بيروت.

(۴۵) المرجع السابق.

(۴۶) فتاوى دارالعلوم ديوبند، ج ۱ ص ۲۰۱ غزنوي كتب خانه.

(۴۷) وقد صرح رجوعه عنه إلى قول علي - رضي الله عنه -، فإنه كان يقول ترد إلى زوجها الأول، ويفرق بينهما وبين الآخر، ولها المهر بما استحل من فرجها، ولا يقرها الأول حتى تنقضي عدتها من الآخر وهذا كان يأخذ إبراهيم - رحمه الله - فيقول: قول علي - رضي الله عنه - أحب إلي من قول عمر - رضي الله عنه -، وبه تأخذ أيضا؛ لأنه تبيين أنها تزوجت، وهي منكوبة ومنكوبة الغير ليست من المحلات بل هي من المحرمات في حق سائر الناس كما قال الله تعالى: (والمحصنات من النساء) [النساء: ۲۴] فكيف يستقيم تركها مع الثاني، وإذا اختار الأول المهر، ولكن يكون النكاح منعقدا بينهما فكيف يستقيم دفع المهر إلى الأول، وهو يدل بضعها فيكون مملوكا لها دون زوجها كالمكوبة إذا وطئت بشبهة، فعرفنا أن الصحيح أنها زوجة الأول، ولكن لا يقرها لكونها معتدة لغيره كالمكوبة إذا وطئت بالشبهة. المبسوط للمرخمي (ج ۱ ص ۳۷) الناشر: دار المعرفة - بيروت.

(۱) که مېړه پر خپلې مېرمنې ظلم کوي، یا یې حقوق نه اداء کوي، یا د زوجینو ترمنځ دښمني وي، مېرمن کولای شي، محکمې ته مراجعه وکړي. (۴۸)

(۲) محکمه، د دې مادې په (۱) فقره کې د درج شوې مېرمنې عریضې ته، د ویرې د شقاق په صورت کې په لاندې ډول رسیدګي کوي:

۱- د اصلاح راوستلو او د ظالم او مظلوم مشخصولو لپاره د زوجینو له اهل څخه د حکمینو ټاکل او زوجینو ته یې لېږل.

۲- د حکمینو له خوا د مشخص شوي ظالم د ظلم مخنیوی کول.

۳- مظلوم ته د حنفي فقهې له حکمونو سره سم، حق ورکول.

۴- متعنت او یا ظالم مېړه، د ظلم او تعنت په ختمولو او یا په طلاق ورکولو مجبورول. (۴۹)

(۳) دا چې د تعنت او د ظلم مخنیوی په نورو طریقو ممکن دی، حکمین او قاضي نه شي کولای د مېړه د تعنت او د ظلم له وجې یوازې د مېرمنې په غوښتنه د مېړه له رضاء پرته خلع او تفریق وکړي. (۵۰)

(۴) د تعنت اړونده نور حکمونه او مسائل په اړونده لایحه کې تنظیمېږي.

اتم فصل

د عیب په سبب تفریق

په مېړه کې د عیب شتون

درې ویشتمه ماده:

(۱) که په مېړه کې، له لاندې عیبونو څخه یو عیب شتون ولري، مېرمن یې کولای شي د تفریق غوښتنه وکړي:

۱- جب (ډګر یې پرې شوی وي).

۲- عنین (ډګر نموځ/انتشار) نه لري.

۳- خصاء (خصي والی/ نه انتشار).

(۲) قاضي دې، د مجبویت په صورت کې سمدلاسه په تفریق حکم وکړي او د عنین یا خصي والي په صورت کې دې، مېړه ته د درملنې لپاره یو کال مهلت ورکړي، که روغ نه شو او مېرمنې د تفریق غوښتنه کوله، قاضي دې د مېرمنې او مېړه ترمنځ په تفریق حکم وکړي. (۵۱)

(۴۸) (ولا یأس به عند الحاجة) للشقاق بعدم الوفاق. (قوله: للشقاق) أي: لوجود الشقاق، وهو الاختلاف والتخاصم. وفي «القهيستاني» عن «شرح الطحاوي»: المنة إذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع أهلها ليصلحوا بينهما، فإن لم يصلحوا جاز الطلاق والخلع، أم «ط». وهذا هو الحكم المذكور في الآية، وقد أوضح الكلام عليه في «الفتح» آخر الباب. [التنوير، والدرر المختار، ج ۲، ص ۶۰۵، باب الخلع، ط: مكتبة رشيدية، كويت].

- [الفتاوى الحقانية، ج ۴، ص ۵۰۹، متعنت کی زوجہ کا حکم، ط: پیشاور].

(۴۹) فتاوی دارالعلوم دیوبند، پښتو، ج ۱۰ ص ۱۸۷. غزنوي کتب خانہ.

(۵۰) فقال أصحابنا: ليس للحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى الزوج وذلك لأنه لا خلاف أن الزوج لو أقربا الإساءة إليها لم يفرق بينهما ولم يجبره الحاكم على طلاقها قبل تعكيم الحكمين وكذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يجبرها الحاكم على خلع ولا على رد مهرها فإذا كان كذلك حكمها قبل بعث الحكمين فكذلك بعد بعثها لا يجوز إيقاع الطلاق من جهتها من غير رضی الزوج وتوكيله ولا إخراج المهر عن ملكها من غير رضاها فلذلك.

قال أصحابنا: إنما لا يجوز خلعها إلا برضى الزوجين فقال أصحابنا ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضى الزوجين لأن الحاكم لا يملك ذلك فكيف يملكه الحكمان وإنما الحكمان ويكلان لهما أحدهما وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج في الخلع أو في التفريق بغير جعل إن كان الزوج قد جعل إليه ذلك. أحكام القرآن للجصاص ت قمعلاوي (ج ۳ ص ۱۵۲).

(۵۱) (وإذا كان الزوج عيّنا أجله الحاكم سنة، فإن وصل إليها فيها، وإلا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك)... (وإن كان مجبواً فرق بينهما في الحال إن طلبت)؛ لأنه لا فائدة في التأجيل، (والخصي يؤجل كما يؤجل العيّن): لأن وطأه مرجو. [الهداية، ج ۲، ص ۲۲۳، باب العنين وغيره، ط: مكتبة رشيدية، كويت].

- (والخصي) الذي نزع خصيتاه (كالعنين) يعني إذا لم تنتشر آلته: لأن وطأه مرجو وإن كان بحيث تنتشر آلته ويصل إلى النساء فلا خيار لها كما صرحوا به (والمجبوب) الذي قطع ذكره وخصيتاه (يفرق) بينهما (للحال) إن طلبت لعدم الفائدة في التأجيل. [مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج ۱، ص ۴۶۳، ط: مكتبة الحرمين الشريفين، كويت].

- (۳) جنون (لېونتوب)، برص (پېس يا برگي والی) او جذام (پمئتوب) هغه عیونه دي چې د زوجینو ترمنځ د تفریق سبب نه ګرځي. (۵۲)
- (۴) که له جماع کولو وروسته، په مېړه کې د جب، عنت او خصي والي عیب پیدا شي، په دې صورت کې مېرمنه د تفریق غوښتنه نه شي کولی. (۵۳)

نهم فصل د ردت په سبب تفریق

له زوجینو څخه د یوه ردت

څلور ویشتمه ماده:

که له زوجینو څخه یو (العیاذ بالله تعالی) مرتد شي، نو د مېړه او مېرمنې ترمنځ فرقت (جلاوالی) راځي، د قاضي حکم په اړه نه لري. (۵۴)

محکمې ته د ارتداد خبر ورکول

پنځه ویشتمه ماده:

که له زوجینو څخه یو مرتد شي، هغه مېرمن یا مېړه چې مسلمان پاتې دی مکلف دی، د موضوع په اړه محکمې ته خبر ورکړي. دې صورت کې قاضي له څېړنې وروسته صورت حال په وثیقه کې درجوي.

لسم فصل

له اسلام څخه د اعراض په سبب تفریق

له اسلام څخه د یو د زوجینو اعراض

شپږ ویشتمه ماده:

- (۱) که په دارالاسلام کې زوجین له اهل کتابو څخه وي، مېړه اسلام قبول کړ، په دې صورت کې د دوی دواړو ترمنځ تفریق نه راځي. (۵۵)
- (۲) که په دارالاسلام کې زوجین له اهل کتابو څخه وي، مېرمنه مسلماننه شي، نو په اسلام قبولولو سره د دوی دواړو ترمنځ تفریق نه راځي، بلکې پرمېړه به یې اسلام عرض شي، که هغه اسلام قبول کړ، نکاح یې پر خپل حال پاتې ده، که هغه اعراض وکړ، نو قاضي دې، د دواړو ترمنځ په تفریق حکم وکړي. (۵۶)

- (۵۲) (وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وقال محمد رحمه الله تعالى: لها الخيار؛ دفعا للضرر عنها كما في الحب والعنة). [الهداية، ج ۲، ص ۲۷۴، باب العنين وغيره، ط: مكتبة رشيدية، كويت].
- (وان وجدت المرأة بزوجها جنونا أو جذاما أو برصا، قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما لله تعالى: ليس لها حق الفرقة. وقال محمد رحمه الله تعالى: لها حق الفرقة). [الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية، ج ۱، ص ۴۱۳، فصل في الخيارات التي تتعلق بالنكاح، ط: مكتبة حبيبیه، كويت].
- (القول الرابع، هو قول الشيخين رحمهما الله تعالى). [القول الرابع، ج ۱، ص ۳۶۷، ط: بيشاور].
- (۵۳) (فلوجب بعد وصوله إليها مرة أو صارت عتيقا بعده لا يفرق). [مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج ۱، ص ۴۶۳، ط: مكتبة الحرمين الشريفين، كويت].
- (۵۴) (ومنها: ردة أحد الزوجين؛ لأن الردة بمنزلة الموت، لأنها سبب مضي إليه، والميت لا يكون محلا للنكاح... والدليل على التفرقة بينهما أن فرقة الإياء لا تحصل إلا بالقضاء، وفرقة الردة تثبت بنفس الردة ليعلم أن ثبوتها بطريق التناهي، ثم الفرقة بردة أحد الزوجين تثبت بنفس الردة، فتثبت في الحال عندنا). [إبدائع الصنائع، ج ۲، ص ۶۲۰، ۶۲۱، ط: مكتبة عثمانیه، كويت]. [هكذا في الدر المختار مع رد المحتار ج ۲، ص ۳۹۲، ط: إيج ايم سعيد، كراتشي].
- (۵۵) (وجملة الكلام فيه: أن الزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما في دار الإسلام، فإن كانا كتابيين، فأسلم الزوج، فالنكاح بحاله؛ لأن الكتابية محل لنكاح المسلم ابتداء، فكذا بقاء). [إبدائع الصنائع، ج ۶، ص ۱۸۴، ط: مكتبة عثمانیه، كويت].
- (۵۶) (وإن أسلمت المرأة لا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندنا، ولكن يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم بقيا على النكاح، وإن أبي الإسلام، فرق القاضي بينهما؛ لأنه لا يجوز أن تكون المسلمة تحت نكاح الكافر، ولهذا لم يجز نكاح الكافر المسلمة ابتداء، فكذا في البقاء عليه). [إبدائع الصنائع، ج ۶، ص ۱۸۴، ط: مكتبة عثمانیه، كويت].

(۳) که په دارالاسلام کې یو د زوجینو اسلام قبول کړي او دواړه مجوسیان یا مشرکان وي، نو د یو د زوجینو په مطلق اسلام قبلولو سره د دوی دواړو ترمنځ تفریق نه راځي، بلکې لومړی به هغه ته چې اسلام یې نه دی راوړی اسلام عرض کړل شي، که یې اسلام قبول کړ، نکاح یې په خپل حال پاتې ده او که یې اسلام قبول نه کړ، نو قاضي دې د دواړو ترمنځ په تفریق حکم وکړي.^(۵۷)

(۴) که په دارالحرب کې یو د زوجینو اسلام قبول کړي، في الحال د دوی ترمنځ فرقت نه راځي، بلکې د دوی فرقت، د مېرمنې تر درې حیضو پورې موقوف دی، که داسې مېرمنه وي چې حیض نه ورځي، بیا تر درېو میاشتو پورې موقوف دی، که په دې موده کې هغه بل یې هم اسلام قبول کړ، نکاح یې پر خپل حال پاتې ده، که موده تېره شوه، اسلام یې قبول نه کړ، نو د دواړو ترمنځ په خپله فرقت راځي.^(۵۸)



یوولسم فصل د دارینو د اختلاف په سبب تفریق

د زوجینو د دارینو اختلاف

اووه ویشتمه ماده:

(۱) که یو له زوجینو څخه دارالاسلام ته په داسې حال کې راشي، چې یا یې اسلام قبول کړی وي او یا دمي شي، یا یې اسلام قبول کړی وي او یا دمي شي، نو د دواړو ترمنځ فرقت راځي.^(۵۹)

(۲) که یو له زوجینو څخه دارالاسلام ته مستأمن داخل شي او هغه بل یې په دارالحرب کې د کفر په حالت پاتې شي، د دوی دواړو ترمنځ فرقت نه راځي.^(۶۰)

دوولسم فصل د لعان او ظهار په سبب تفریق

د لعان حکم

اته ویشتمه ماده:

که د مېرمنې او مېر ترمنځ لعان واقع شي، قاضي دې د دوی ترمنځ په تفریق حکم وکړي.^(۶۱)

د ظهار حکم

نهمه ویشتمه ماده:

که یو شخص له خپلې مېرمنې سره ظهار وکړي، نو د دوی ترمنځ د کفارې تر اداء کولو پورې حرمت راځي؛ کله چې کفاره یې اداء کړه، حرمت یې بېرته ختمېږي؛ که مېر نه کفاره اداء کوي، نه طلاق ورکوي او مېرمنه د وطي (کوروالي) غوښتنه وکړي، نو قاضي دې، مېر

(۵۷) (وإن كانا مشرکین أو مجوسین، فأسلم أحدهما أتتھا کان یعرض الإسلام علی الآخر، ولا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندنا، فإن أسلم، فهما علی النکاح، وإن أبی الإسلام، فرق القاضي بينهما؛ لأنَّ المشرکة لا تصلح لنکاح المسلم). [بدائع الصنائع، ج ۶، ص ۱۸۴، ط: مکتبه عثمانیه، کویته].

(۵۸) (ومنها: إسلام أحد الزوجین فی دار الحرب لکن لا تقع الفرقة فی الحال بل تقف علی مضی ثلاث حیض إن کانت من حیض، وإن کانت من لا تحيض ثلاثة أشهر، فإن أسلم الباقي منهما فی هذه المدة، فهما علی النکاح، وإن لم یسلم حتی مضت المدة وقعت الفرقة). [بدائع الصنائع، ج ۶، ص ۱۹۰، ط: مکتبه عثمانیه، کویته].

(۵۹) (ومنها: اختلاف الدارین عندنا بأن خرج أحد الزوجین إلى دار الإسلام مسلماً أو ذمیاً، وترك الآخر کافراً فی دار الحرب... وكذلك إذا خرج أحدهما ذمیاً وقعت الفرقة). [بدائع الصنائع، ج ۶، ص ۱۹۱، ط: مکتبه عثمانیه، کویته].

(۶۰) (ولو خرج أحدهما مستأمنًا، وبقي الآخر کافرًا فی دار الحرب لا تقع الفرقة بالإجماع).

[بدائع الصنائع، ج ۶، ص ۱۹۱، ط: مکتبه عثمانیه، کویته].

(۶۱) - (قال: وإذا اتعنا لا تقع الفرقة حتی یفرق القاضي بينهما). [الهدایة، ج ۲، ص ۳۹۷، ط: مکتبه رشیدیة، کویته].

- (قال أصحابنا الثلاثة -رحمهم الله تعالی-: هو وجوب التفریق ما دام علی حال اللعان، لا وقوع الفرقة بنفس اللعان من غیر تفریق الحاكم، حتی یجوز طلاق الزوج، وظهاره، وإلاؤه ویجری التوارث بينهما قبل التفریق). [بدائع الصنائع، ج ۳، ص ۲۴۴، فصل فی حکم اللعان، ط: مکتبه عثمانیه، کویته].

د كفارې پر اداء كولو مجبور كړي، كه مېړه نه كفاره اداء كړي او نه طلاق وركړي، نو قاضي دې، هغه په بندي كولو او وهلو د كفارې اداء كولو ته اړ كړي يا خپلې مېرمنې ته دې طلاق وركړي.

البته ترهغه وخته پورې چې مېړه كفاره اداء نه كړي، تر هغې پورې مېرمنې ته له مېړه سره نږدېكت كول جواز نه لري.^(٦٢)

دوهم باب

متفرقه حكمونه

د طرز العملونو تدوين

دېرشمه ماده:

د افغانستان اسلامي امارت ستره محكمه كولای شي، د دې اصولنامې د حكمونو د ښه تطبيق په منظور، طرز العملونه تدوين كړي.^(٦٣)

انفاذ او خپرول

يو دېرشمه ماده:

دغه اصولنامه د توشيح له نېټې څخه نافذه^(٦٤) او په رسمي جريده كې دې خپره شي^(٦٥) او نورې هغه اصولنامې او قوانين چې د حفظه الله تعالى له خوا تاييد، منظور يا توشيح شوي نه وي او يا له دې اصولنامې سره مغاير وي، ملغى دي.^(٦٦)



(٦٢) - (قوله: ويسقط حقها بمرة)... وسيأتي في باب الظهار: أن على القاضي إلزام المظاهر بالكفر: دفعا للضرر عنها، بحسبى أو ضرب إلى أن يكفر أو يطلق). [ارد المحتار، ج ٣، ص ٢٠٣، ط: ايچ ايم سعيد، كراتشي].

- (وحكمه حرمة الوطء، والدواعي إلى وجود الكفارة. (قوله: إلى وجود الكفارة) أي: مع بقاء أصل النكاح: لقوله عليه الصلاة والسلام: للمظاهر المواقع استغفر الله ولا تعد حتى تكفر، اه أنقاني. (قوله: ونقل حكمه إلى تحریم مؤقت) أي: من غير أن يكون الظهار مزيلًا للنكاح: كالحيض يحرم به الوطء إلى وجود الطهر من غير أن يزول النكاح، اه). [مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج ١، ٤٢٨، ط: مكتبة الحرمين الشريفين، كويت].

- (وينبغي لها) أي: يجب لها (أن تملع نفسها منه) إلى أن يكفر (وتطالبه بالكفارة ويجبره القاضي عليها) بالحبس، ثم بالضرب إن أبي دفعا للضرر عنها)

[مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج ١، ٤٢٨، ط: مكتبة الحرمين الشريفين، كويت]. والله تعالى اعلم وعلمه أتم وأحكم

(٦٣) - أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من الواجبات وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة. (توضيح الأحكام من بلوغ المرام ج ٤ ص ٢٧٨)

- أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلزمها من الواجبات وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة. (توضيح الأحكام من بلوغ المرام ج ٤ ص ٢٧٨)

(٦٤) - قال في المعراج: لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة اه [الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار ج ٢، ص ١٧٢ الناشر: دار الفكر - بيروت].

- [مطلب طاعة الإمام واجبة] [قوله: أمر السلطان إنما ينفذ] أي يتبع ولا تجوز مخالفته... أن طاعة الإمام في غير معصية واجبة. [الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج ٥ ص ٤٢٢ الناشر: دار الفكر - بيروت].

- أمر الأمير متى صادف فصلا مجهدا فيه نفذ أمره، كما في سير التتارخانية وشرح السير الكبير فليحفظ. [الدر المختار وحاشية ابن عابدين، ج ١، ص ٧٦، الناشر: دار الفكر - بيروت].

- وكذلك إن أمرهم بشيء لا يبرون أينفعون به أم لا، فعلمهم أن يطيعوه، لأن فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به. [شرح السير الكبير ج ١، ص ١٦٥، الناشر: الشركة الشرقية للإعلامات].

(٦٥) وأما الإعلان في الجرائد فلم تكن أوراق حوادث في عصر الفقهاء كما هو في زماننا فلا يوجد بحث في الكتب الفقهية بشأن الإعلان بهذه الوسيلة. ولكن الإعلان في زماننا بواسطة الأوراق المذكورة أيضا جائز. ولكن بما أنه ليس كل الناس يقرأون الجرائد ويعرفون قراءتها وبما أنه لا توجد جرائد في كل محل فيجب الإعلان أيضا بواسطة المنادي في مجامع الناس كما قال الفقهاء. [درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج ٢، ص ٢٤٩، الناشر: دار الجليل].

(٦٦) - والأصل أن الشيء يبطل بمثله، وبما فوقه لا بما دونه. [الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ج ١، ص ١٠٦، الناشر: دار الكتب العلمية].

- أن من يعرض عليه قانون يأخذ منه أمرا ياتبع قانون من قبله بأن يكتب أمرا بإتباعه. [تقريرات الرافعي ضميمه حاشية ابن عابدين ج ١٦ ص ٥٩٨ ط دار السلام دمشق].

- والشيء يبطل بمثله وبما هو فوقه. [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ١٦، ص ١٧٩، الناشر: دار الكتب العلمية].

- الشيء يبطل بمثله كما يبطل بأقوى منه. [فتح باب العناية بشرح النقاية ج ١، ص ٤٨١].